

1500720-73.2022.8.26.0210

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... delito é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500720-73.2022.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500720-73.2022.8.26.0210

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Raniel Ribeiro dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. RANIEL RIBEIRO DOS SANTOS, qualificado a fls. 11, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 1º de setembro de 2022, por volta das 10h30min, na Rua 36 nº 1.305, Bairro Vila

Aparecida, nesta cidade e Comarca de Guaíra, teria trazido consigo, com finalidade de traficância e entrega ao consumo de terceiros, quarenta porções de cocaína, com peso aproximado de 8,330 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

É da denúncia que na data do ocorrido "policiais militares estavam em patrulhamento quando, na Rua 36 com a Avenida 25, depararam-se com o denunciado, o qual conduzia uma bicicleta.

Ao perceber a presença dos agentes públicos, RANIEL empreendeu fuga, retirando de suas vestes um invólucro e o arremessando no quintal de uma residência.

Os policiais, depois de abordarem o denunciado, foram ao local onde ele havia lançado o invólucro mencionado, no interior do qual encontraram as drogas acima descritas.

No bolso da bermuda de RANIEL, os policiais localizaram, ainda, um telefone celular e a quantia de cento e cinco reais e cinquenta centavos em cédulas predominantemente de cinco reais, valor informado pelo denunciado como o cobrado por cada pino que vendia.".

A denúncia de fls. 62/63 foi recebida em 4 de outubro de 2022 (fls. 84/85), sendo o Réu citado a fls. 124, apresentado defesa preliminar em fls. 93/97, rejeitada em fls. 100/101. Durante a instrução foi colhida prova oral e interrogado o Réu (fls. 141).

Em memoriais, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 139/140).

A douta Defesa, por seu turno, arguiu preliminares e no mérito requereu a improcedência da ação, alegando não existir prova que permitisse a condenação, pleiteando a absolvição, com, a restituição do aparelho de telefonia celular apreendido e, em pedido subsidiário, requereu fosse concedido o privilégio previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, a concessão de regime aberto para cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 143/165).

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

As preliminares arguidas em memoriais defensivos de ligam ao mérito e serão ali analisadas.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está estampada no auto de prisão em flagrante de fls. 01/05, no boletim de ocorrência de fls. 05/06, auto de exibição e apreensão de fls. 08, no auto de constatação preliminar de fls. 09, comprovante de depósito de fls. 50, pelo laudo de exame químico-toxicológico a fls. 55/57, além da prova oral colhida durante a persecução.

A autoria é certa contra o Réu que, na fase inquisitorial optou pelo silêncio (fls. 04), ao passo que em Juízo negou o teor da denúncia, sustentando que tinha saído da residência de sua genitora, subia a Avenida 25 quando encontrou um amigo na esquina da 36, com ele fumando maconha, sendo que seu colega, ao avistar a viatura, empreendeu fuga e ele deu marcha com sua bicicleta, somente carregando o cigarro de maconha, quando, então, foi derrubado da bicicleta pelos policiais e agredido, sendo colocado na viatura, foram até uma casa procurar algo até que chegou outra viatura e, logo em seguida, saíram com o entorpecente. Ademais, faz uso de maconha e trabalha em uma auto elétrica.

De início deve ser destacado que, como se sabe, o direito ao silêncio é cláusula constitucionalmente assegurada, mas não é crível se acreditar que aquele que tenha sido injustamente preso pela prática de um crime assemelhado ao hediondo tivesse a frieza de manter-se calado para somente em Juízo informar a prisão equivocada, demonstrando que o Réu nada tinha a indicar em sua defesa no momento de sua prisão, cabendo salientar brilhante excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, pois ele “assumiu comprometedora, ainda que legalmente tolerada, postura silente, quando é certo que aquele que se vê injustamente acusado, trata, logo, de anunciar a injustiça da acusação, se convidado a falar sobre ela” (TJSP, Ap. 990.09.059887-5, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 04.08.2009).

O policial militar Givanildo declarou que estavam em patrulhamento quando se depararam com o Réu na Avenida 25 com a 36, conhecido ponto de venda de drogas, e ele, ao avistar a viatura, empreendeu fuga com sua bicicleta, retirando algo de sua cintura e jogando em uma casa, sendo detido e consigo encontrado dinheiro em notas de R\$ 5,00, em sua maioria e um telefone celular. Retornaram na residência onde a sacola foi lançado, se tratado de uma casa murada e toda fechada (não a casa verde, ao lado) e lá, com o auxílio de uma escada, encontraram a droga que estava na sacola, indagando o Acusado, que disse que vendia a porção por R\$ 5,00. Ademais, o Réu não aparentava estar sob efeito de entorpecentes e é conhecido dos meios policiais.

No mesmo sentido o depoimento do policial Marcus, que ainda destacou que o Réu foi preso cerca de meio quarteirão à frente, acessaram a casa através de escada colocada na residência do lado, que estava com o portão aberto, sendo que o entorpecente estava em no corredor lateral da casa fechada e, por fim, que o Réu estava sozinho.

A testemunha de defesa LisLaura declarou que residia três casas à frente daquela em que houve a apreensão da droga, afirmando que estava com sua irmã na calçada quando o Réu subia a rua, assim como a viatura, sendo o Acusado derrubado da bicicleta pelos policiais, que passaram a lhe agredir com chutes, os quais, na sequência, o colocaram na viatura e foram para a casa em frente, cujo portão estava aberto, ingressando até a residência dos fundos. Não viu a droga sendo encontrada, os policiais saíram e depois de um tempo pediram uma escada, retornando ao local, sendo que a diligência demorou cerca de trinta minutos e, quando chegou uma segunda viatura, dois minutos depois saíram os policiais com algo na mão.

A versão desta testemunha de defesa não encontra amparo nos autos. Não se trata de privilegiar o depoimento dos policiais pelo da testemunha defensiva, mas sim não se admitir o testemunho que aparentemente é escorado em versão falsa. De fato, conforme sobredito, o Réu permaneceu pelo silêncio quando preso, o que não é de se supor que o faria caso tivesse sido injustamente acusado de um crime desta natureza. Some-se a isso que o laudo médico de fls. 21, realizado quando de sua prisão, foi enfático ao descrever ausência de lesões, o que, com a devida vênia, não ocorreria em alguém que, naquele dia, tivesse sido agredido a chutes por policiais. Isso, convém ressaltar, não configura cerceamento de defesa, como pretendeu fosse reconhecido o Réu em seus memoriais, porquanto deve ser dado o valor que cada testemunho possa valer e, no caso em tela, o depoimento da testemunha em questão não espelhou a realidade e, fosse mesmo a situação presenciada por “toda a rua” (fls. 146), não ficaria neste depoimento isolado, quanto mais quando atualmente quase todas as pessoas possuem telefone celular que realizaram gravações, o que certamente ocorreria caso a população presenciasse, à luz do dia, um inocente sendo cruelmente agredido por agentes públicos.

A conduta do Acusado, pois, indica que no dia, horário e local apontados na denúncia, trazia consigo substância entorpecente para fins de traficância. A isso se chega com a prova coligida aos autos, notadamente a considerável quantidade de cocaína apreendida (sendo que ele alegou ser somente usuário de maconha), ser

conhecido dos meios policiais pela prática deste crime, estar em notório ponto de venda de drogas, a tentativa de fuga, a confissão informal dada aos policiais no momento da prisão, sendo, ademais, que não demonstrou exercer ocupação lícita. Some-se a tudo isso que apesar de jovem, o Réu conta com condenação criminal por tráfico de drogas, conforme será abaixo mencionado. Tais condutas apontam que o Réu utilizava o entorpecente apreendido para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006.

Dessa forma, considerando o quadro posto, descabe se falar em insuficiência probatória, inclusive sobre a ausência de prova de atos de comércio, desnecessário diante do contexto probatório. Oportuno salientar que "Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado" (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

Nem se olvide pelo fato de a acusação se embasar somente no depoimento prestado por policiais, que é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, não podendo ser descartados, notadamente porque o Réu não ofertou qualquer resistência válida ao depoimento dos militares.

A condição funcional não os torna suspeitos, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão, "Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos.

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram" (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

A alegação de invasão de domicílio deve ser refutada, considerando que o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 10.343/06 é classificado como permanente, de modo que a consumação se arrasta no tempo e permite a prisão em flagrante a qualquer momento, mormente quando, no caso em julgamento, dúvida alguma há de que o Réu não morava naquela residência e somente jogou o entorpecente durante a fuga, não havendo que se falar em invasão, sendo que a proteção constitucional é específica para evitar o ingresso desautorizado, fora de hipótese de flagrante, na residência do autuado, situação muito longe da que se desenha nestes autos. De qualquer forma, não era necessária autorização judicial para ingressar na residência em que se encontrava o Acusado, agindo os agentes policiais dentro da exceção à regra constitucional da inviolabilidade do domicílio, insculpida no artigo 5º, inciso XI, da CF/88: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial" (destaquei).

Sobreleva destacar, de outro modo, a petição de fls. 134/136, com a devida vênia, nada esclarece sobre os fatos, mormente porque, em audiência, a douta patrona confrontou o primeiro policial ouvido como testemunha com imagens e este destacou precisamente a residência onde localizada a droga, ao passo que o segundo depoente,

em reforço, deu conta que a casa ao lado (verde) somente foi utilizada para que tivessem acesso ao imóvel vizinho, por meio de escada.

Assim, tem-se o depoimento isolado do Réu que, por motivos óbvios, possui intenção de se isentar das penas da narcotraficância e, de outro lado, o depoimento uníssono dos policiais militares, agentes públicos que contaram com detalhes a prisão do Réu, nada sendo levantado e muito menos comprovado contra eles, de forma que viesse a colocar em xeque seus depoimentos.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade. Sendo assim, reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O Acusado ostenta maus antecedentes, que, contudo, não podem ser utilizados para não incorrer em bis in idem com a reincidência. Contudo, nesta fase inicial, apreciando os parâmetros legais ditados pelo artigo 59 do Código Penal e pelo artigo 42 da Lei de Drogas, é o caso de majorar a pena-base, tendo em vista que o Réu, quando menor de idade, teve várias passagens por atos infracionais (cf. fls. 25), demonstrando que apesar de jovem persiste na prática de ilícitos, com claro indicativo da periculosidade do agente. Ressalto que se não é viável a majoração da pena por passagens pela Justiça menorista, é certo ser possível, nesta fase, a majoração diante da existência de atos infracionais como critério de majoração da pena em decorrência da personalidade do agente, o que aqui se faz porque, mesmo atingindo a maioridade penal há pouco tempo, evidencia persistência na prática de condutas antissociais que não podem ser ignoradas, verbis: "A Terceira Seção desta Corte firmou orientação de que 'os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social. Se os atos infracionais não servem, por óbvio, como antecedentes penais e muito menos para firmar reincidência (porque tais conceitos implicam a ideia de 'crime' anterior), não podem ser ignorados para aferir a personalidade e eventual risco que sua liberdade plena representa para terceiros" (RHC n. 63.855/MG, rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Dje 13/6/2016)'. " (STJ, RHC 96.158/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.08.2018).

Por isso, promovo o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) e a fixo inicialmente em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor patamar, à míngua da comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase aumento sua pena em 1/3 (um terço) em razão da reincidência específica (cf. fls. 23/24, autos nº 1500459-16.2019.8.26.0210), atingindo o patamar de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Sendo reincidente específico e detentor de periculosidade, pelos motivos expostos linhas acima, o Acusado não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que nem mesmo há prova de ocupação lícita, demonstrando que se dedica, exclusivamente, à atividade criminosa do comércio clandestino de venda de drogas. Dessa maneira, torno aquela pena definitiva, ante a inexistência de demais causas legais modificadoras.

Importante consignar que caberia à Defesa a prova de que o Acusado faria jus à causa de diminuição mencionada, considerando-se que esta não é automática e somente de aplicação possível quando presentes os requisitos legais, forte no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal. Desta forma, o Réu deveria indicar, através de provas robustas que trabalhava e não se dedicava a atividades criminosas, afastando o quanto foi comprovado pela Acusação, isto é, que estava em ato de traficância.

Nesse diapasão: "Para redução da pena, essencial que o réu seja 'primário', apresente 'bons antecedentes', comprove que 'não se dedique às atividades criminosas', assim como, 'nem integre organização criminosa'. Evidente que essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder. Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução" (TJSP, Ap. 0003548-97.2014.8.26.0210, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, j. 30.07.2019).

O regime de cumprimento de pena adequado, por se tratar de crime equiparado ao hediondo e por ser o Réu portador de péssimos antecedentes, inclusive reincidente específico, é o inicial fechado. Nesse panorama: "O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto, não só por previsão legal artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas, considerado o § 4º, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave.

Mas há os considerados hediondos.

Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo, absolutamente intolerável.

Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?

O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o 'crack', por exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de recuperação. Bem por isso que se trata de crime hediondo.

A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.

O legislador, com a edição da Lei nº 11.343/06, passou a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.

Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.

Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos os preocupa" (TJSP, Ap.

Por outro lado, é vedada a concessão de sursis ou substituição por pena restritiva de direitos, pela ausência dos requisitos subjetivo e objetivo. Ressalto, quanto tal aspecto que, não obstante a decisão tomada no HC 97.256/RS, do STF, que não possui cunho vinculante, com a devida vênia, não se verifica compatibilidade lógica da pena restritiva com a natureza da infração, sendo que deveria a defesa fazer prova de que o Acusado possui condições da substituição da pena corporal, o que não é afastado nem mesmo diante da Resolução nº 5/2012 do Senado, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto esta deve se dar respeitando parâmetros preestabelecidos pela lei, notadamente porque o artigo 5º, inciso XLIII, da CF/88 determinou regime mais rigoroso na reprimenda de crimes hediondos e equiparados.

Ressalto, ainda, que a disposição do artigo 44 do Código Penal, que trata da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é de aplicação automática, pois elenca os requisitos legais para tanto. Ali, em seu inciso III, estabelece que somente é aplicável a comutação quando a conduta social do réu, além dos motivos e circunstâncias do delito, forem favoráveis. A simples prática do narcotráfico, este o flagelo de nossa sociedade, indica o sujeito ativo do crime como pessoa portadora de péssima conduta social, sendo que os motivos e circunstâncias do crime são, evidentemente, desfavoráveis. Para isso, basta se ter contato com um usuário de entorpecente para se verificar a miséria que se tornou sua existência (e de sua família), tão-somente pelo consumo daquilo que é oferecido pelo traficante (ainda que seja um "pequeno" traficante).

Para o crime de narcotráfico, circunstâncias como primariedade, bons antecedentes ou emprego lícito servem para fixar a pena aplicada, bem como, quando o caso, o critério redutor. Contudo, não viabiliza a conversão em pena restritiva ou mesmo a fixação em regime que não o fechado, em vista dos diplomas legais acima citados, pois insuficiente à repressão e prevenção desta infração equiparada ao crime delito hediondo. Nesse sentido, lapidar excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, verbis: "Ressalta-se que a decisão apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não possuindo efeito 'erga omnes', até porque, não afastada pela Suprema Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012; HABEAS CORPUS 216.265/SP. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.06.2012; HABEAS CORPUS 199.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.08.2012; e HABEAS CORPUS nº 225.568/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe. 27.08.2012.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, havendo a necessidade de pronunciar algumas considerações.

Com efeito, o Senado, na forma do artigo 52, inciso X da Constituição Federal e com olhos voltados para o julgamento do HC nº 97.256/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Resolução nº 05/2012, cujo teor é a suspensão da parte que obstaculizava a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, inserida no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.

Em vista o postulado implícito da proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, Ed. Malheiros), que é uma espécie de norma jurídica derivada do devido,

justo e adequado processo legal (FAIR TRAIL), não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, pondera-se: de onde viria o numerário para o traficante cumprir a prestação pecuniária? E mais: onde o traficante, disseminador de vício, cumpriria prestação de serviços à comunidade ou entidade pública? Nas escolas? Nas creches? Nos orfanatos? Nos abrigos? Nos hospitais?

Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do 'DUE PROCESS OF LAW'.

Além disso, é válido ressaltar que os recentes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicam que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas, isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012).

E, na espécie, como foram apreendidas porções consideráveis de 'maconha', a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da atividade ilícita" (TJSP, Ap. 0005407-56.2011.8.26.0210, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 18.12.2012).

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

À derradeira, tendo em vista que o Acusado foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo apreendidos celulares e quantia em dinheiro sem comprovação de regularidade em seu recebimento, evidenciando-se serem relacionados à venda de drogas ilícitas, com fulcro no artigo 63, caput, do aludido diploma legal, decreto a perda dos bens e valores apreendidos com o Réu, depositados em Juízo, que deverão ser encaminhados em favor da União, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º), ficando indeferido o pedido de restituição.

III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência CONDENO o Réu RANIEL RIBEIRO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, em seu piso legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, vedada a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis. No mais, decreto a perda dos bens e do dinheiro apreendidos com o investigado, em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), bem como encaminhe-se o numerário e os bens apreendidos, em benefício da União.

Diante da pena aplicada, em regime inicial fechado em razão da equiparação à hediondez do crime, o Réu, descontente com a decisão, deverá aguardar o julgamento do recurso preso, motivo por que mantenho sua prisão cautelar, sem prejuízo da apelação, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do CPP.

São devidas custas na forma da lei, delas ficando o Réu isento por ser beneficiário

da Justiça Gratuita, pedido que ora defiro uma vez presentes os requisitos legais.

Sem prejuízo, havendo indícios de que a depoente LisLaura Figueiredo da Cunha, ouvida em Juízo, tenha prestado falso testemunho, requirite-se instauração de inquérito policial para investigar o fato, encaminhando-se, para tanto, cópia destes autos.

P.R.I.C.

Guaíra, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA